

刑法

No.99

H24-9

(配点: 2)

月 日

月 日

緊急避難に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 緊急避難の要件である「現在の危難」は、人の行為によるものに限られないから、自然災害もこれに含まれる。
2. 緊急避難が成立するのは、避難行為により避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に限られ、前者と後者が同等の場合には成立しない。
3. 緊急避難の要件である「現在の危難」が認められる場合であっても、第三者の正当な利益を侵害することは認められないから、現在の危難を避けるために第三者の法益を侵害したときには、緊急避難は成立しない。
4. 緊急避難の要件である「現在の危難」は、正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」とは異なり、法益に対する侵害が現実存在することを意味し、侵害が差し迫っているだけでは足りない。
5. 避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが、危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には、過剰避難が成立し得る。

No99	緊急避難	正答率
H24-9	正 解 1、5 (順不同)	84%

1 正しい

大判昭8.11.30。緊急避難の要件である「現在の危難」(37条1項本文)に自然災害も含まれるかについて、判例は、豪雨で自己の耕作する水田が湛水し、田植えをしたばかりの稲苗が増水のため水没して枯死する恐れがあったため、排水を妨げていた水利組合の管理する川の板堰を損壊したという事案において、「現在の危難」に自然災害が含まれるとしている。

2 誤っている

37条1項。緊急避難が成立するためには、「やむを得ずにした行為…によって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」(37条1項本文) ことが必要である(法益権衡の原則)。正当防衛の場合とは異なりこのような法益の権衡が要求されるのは、緊急避難が「正」対「正」の関係にあるためである。そして、法益権衡の原則の要件が充足されるためには、保全法益(回避された法益侵害)が侵害法益(生じさせた法益侵害)と同程度か、それよりも優越することが必要であると解されている。

3 誤っている

本記述では、現在の危難を避けるために第三者の法益を侵害したときにも緊急避難が成立するかが問題となる。緊急避難は、危険が差し迫っている法益を救うために特に許された行為である点で正当防衛と類似した性格を有するが、正当防衛が不正な侵害者に対して反撃することを正当なものとするという「不正」対「正」の関係にあるのに対し、緊急避難は、現在の危難を避けるために無関係な第三者の法益をやむを得ず侵害する行為を「正」として扱うものである。よって、緊急避難においては、「現在の危難」を避けるため第三者の正当な利益を侵害することも認められている。

4 誤っている

本記述では、「現在の危難」とは、正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」と異なり、法益に対する侵害が現実存在することを意味し、侵害が差し迫っているだけでは足りないかが問題となる。「現在の危難」(37条1項本文)とは、現に危難の切迫していること(最大判昭24.5.18)、すなわち、危難が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいい、正当防衛における「急迫」と同義である(最判昭24.8.18)。

5 正しい

過剰避難とは、避難行為が「その程度を超えた」(37条1項ただし書)場合をいい、緊急避難行為により侵害利益が保全利益の程度を超え法益権衡の原則を逸脱した場合には異論なく成立する(堺判昭61.8.27他)。本記述は、法益権衡の原則を逸脱するが、補充性の原則を充たしているもので、異論なく過剰避難の成立が認められる。